

1500196-63.2022.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... prisões no local em razão do crime de tráfico; que se posicionaram nas proximidades com viatura descaracterizada; que algumas imagens foram captadas de uma mulher de camiseta verde e chinelo, e de um homem de camisa estampada e bermuda, que pessoas se encontravam com eles e trocavam algo, em atitude típica de tráfico de drogas; que, em dado momento, um rapaz de camiseta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

1ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500196-63.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500196-63.2022.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163805/2022 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 25595339 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2163805 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELENI AGUIAR DOS REIS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de GERSON DA CRUZ LIMA e ELENI AGUIAR DOS REIS, qualificados nos autos, em decorrência da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia (fls. 122/123), em data de 15 de junho de 2022, às 15 horas e 50 minutos, na Rua João Felizardo, esquina com a Rua Rio Madeira, Vila Antunes, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga, GERSON DA CRUZ LIMA e ELENI

AGUIAR DOS REIS traziam consigo 09 (nove) eppendorf's contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 15,95 gramas, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o Ministério Público: "Conforme o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima, os denunciados estavam vendendo drogas a diversos usuários. Um dos usuários, inclusive, foi identificado como sendo Amarildo Sobral Rodrigues. Ocorre, porém, que Policiais Cíveis realizaram campana no local e registraram, por fotografias, a venda dos entorpecentes (fls. 22/32). Realizada a abordagem pelos policiais, os denunciados foram presos em flagrante, ocasião em que ELENI AGUIAR DOS REIS foi surpreendida na posse de R\$ 40,00 e nove pinos de cocaína. Interrogados em solo policial, os denunciados disseram que somente irão se manifestar em juízo na presença de um defensor (fls. 08/09)".

Decisão de fls. 84/87 converteu a prisão em flagrante de GERSON em prisão preventiva e concedeu liberdade provisória à ELENI.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no âmbito do qual foram encadernadas, entre outras, as seguintes peças: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termos de declarações e interrogatório (fls. 03/04, 05, 06/07, 08 e 09), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), fotografias (fls. 22/32), além do Relatório lavrado pela Autoridade Policial (fls. 112/118).

Laudo definitivo de exame químico-toxicológico foi juntado às fls. 169/170.

Notificados, os Réus apresentaram Defesas Prévias às fls. 145/146 e 147, através da atuação de Defensores Dativos.

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2022 pela decisão de fls. 151/152 e, não caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária, designou-se Audiência de Instrução e Julgamento.

Em Audiência de Instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, bem como, ao final, os Réus foram interrogados (fls. 193/194).

Sobrevieram as alegações finais do Ministério Público, pugnando, em breve síntese, pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. A Defesa Técnica de GERSON, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, com a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos. A Defesa Técnica de ELENI, por fim, em sede de memoriais, pleiteou a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, com a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos (fls. 195/199).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise de mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência; em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. Na situação sob

juízo, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos através do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, do boletim de ocorrência de fls. 12/14, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 17, do auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, das fotografias de fls. 22/32, do laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 169/170 – no qual fora detectada a presença da substância entorpecente cocaína –, bem como a partir das provas orais colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra, além de qualquer dúvida razoável, que os acusados GERSON DA CRUZ LIMA e ELENÍ AGUIAR DOS REIS foram os autores do delito em análise, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, a despeito das alegações da Defesa Técnica, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um decreto condenatório.

Ouvido em sede policial, a testemunha Armando Marcio Costa, policial civil, narrou que: “na data de hoje, ainda no período da tarde, eu juntamente com meu colega Nelson Galdino de Oliveira nos deslocamos até a cidade de Cajati/SP, mais especificamente no Bairro Vila Inhunguvira, na Rua João Felizardo esquina com a Rua Rio Madeira (Bar do Banana), a fim de combater o tráfico de drogas. Este local já é ponto conhecido desta Delegacia Especializada, como ponto de venda de drogas “biqueira”. Nos aproximamos do citado local com viatura descaracterizada e começamos a fazer a visualização deste (“campana”), bem como a captação de imagens. Logo após, já avistamos uma mulher vestindo uma blusa verde e shorts jeans, calçando chinelos e um homem vestindo camisa florida e bermuda listrada colorida, calçando chinelo, que ficavam se deslocavam de um lado para o outro da rua atendendo e fazendo trocas com pessoas com características de usuáries. Na sequência foi também avistado e captado imagens da pessoa do sexo masculino (vestindo camisa florida e bermuda listrada colorida, calçando chinelo) pegando o dinheiro com essas pessoas com características de usuáries e também entregando entorpecentes e a pessoa do sexo feminino (vestindo uma blusa verde e shorts jeans, calçando chinelos) entregava os entorpecentes. Em uma das situações, nos acompanhamos um desses possíveis usuáries, que vestia um boné, camiseta vermelha e bermuda preta, calçando chinelos, nós acompanhamos esse usuário logo após deixar o local e o abordamos, em revista pessoal foi localizado 01 (um) pino de cocaína, inquirido, relatou que havia comprado estas 01 pino de cocaína para seu uso pagando R\$ 10,00 na esquina do Banana. Diante desta situação flagrancial, deslocamos até local com viatura caracterizada, (Rua João Felizardo com a Rua Rio Madeira), Inhunguvira, onde avistamos a mulher vestindo uma blusa verde e shorts jeans, calçando chinelos e o homem vestindo camisa florida e bermuda listrada colorida, calçando chinelo, ambos foram abordados, não sendo encontrado nada de ilícito com o rapaz, em deslocamento para a Delegacia, a pessoa do sexo feminino entregou o valor de R\$ 40,00 para nós. Na Delegacia, essa pessoa do sexo feminino foi revistada por uma policial também do sexo feminino, quando encontrou na lateral de seu shorts 09 (nove) pinos de cocaína. Destaca-se que diante da forte repressão ao tráfico de drogas por parte desta Delegacia Especializada e pela Polícia Militar naquele local, os traficantes de drogas estão adotando a estratégia de ficar com pouca droga para comercializar visando se passar por usuáries de drogas e também ter um prejuízo menor para a organização criminosa. Diante desta situação fática foi dada voz de prisão em flagrante pelo delito de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) indiciado Gerson da Cruz Lima e a indiciada Eleni Aguiar dos Reis. Amarildo Sobral Rodrigues foi conduzido para esta Delegacia, por ter incidido na conduta (porte para uso) do artigo 28 da Lei 11.343/06, figurando também como testemunha no procedimento da prisão em flagrante. Foi necessário o uso de algemas nos indiciados, diante da possibilidade real de fuga como ocorreu, em outras vezes no mesmo local, isso em consonância com o decreto 8.858/16” (fls. 06/07).

Em seu depoimento em Juízo, confirmou, sob compromisso, seu relato inicial. Afirmou que o local dos fatos é conhecido como "beco do banana", ponto conhecido de venda de drogas na cidade; que se trata de um dos pontos de vendas de drogas mais movimentados da cidade de Cajati; que, no dia dos fatos, ele e seu colega de farda chegaram ao local com viatura descaracterizada para operação de combate ao tráfico de drogas; que, então, perceberam a presença de dois indivíduos, uma mulher e um homem; que a mulher estava de blusa verde e de bermuda e o homem de camisa florida e de bermuda, depois identificados como GERSON e ELENI; que ora GERSON trocava algo com indivíduos que aportaram no local, ora era ELENI que o fazia, em atitude típica de tráfico de drogas; que GERSON e ELENI conversavam e estavam atuando em conjunto naquele dia; que foram captadas imagens de tais movimentações; que conseguiram abordar um usuário e com ele foi encontrado um pino de cocaína; que este apenas disse que havia comprado um pino de cocaína no beco do banana, mas não descreveu as características físicas da pessoa que lhe vendeu a droga; que, então, abordaram o casal; que nada de ilícito foi encontrado com GERSON; que, com ELENI, foram encontrados 09 pinos de cocaína depois de busca pessoal realizada por policial feminina; que, no trajeto até a delegacia de polícia, ELENI entregou 40 reais aos policiais; que os pinos de cocaína encontrados com ELENI eram semelhantes àqueles encontrados com o usuário que foi abordado naquele dia; que, então, deram voz de prisão a ambos, a qual foi ratificada pela Autoridade Policial; que, ao serem abordados, os acusados exerceram o direito de ficar em silêncio; que GERSON já havia sido abordado em outras oportunidades, em atitude suspeita, no mesmo local; que não foi realizada tentativa de reconhecimento pessoal pela testemunha Amarildo; que as fotografias apresentadas nos autos foram feitas por si e pelo policial Nelson de dentro da viatura descaracterizada; que Amarildo foi abordado fora do local dos fatos; que logo depois, houve troca de veículo para realização da abordagem dos acusados; que toda a ação foi bem rápida; que não era possível para os que estavam presentes no local verem a atuação da polícia no dia. Em sentido semelhante foi o depoimento da testemunha Nelson Galdino de Oliveira, também policial civil, ao longo da primeira fase da persecução penal (fls. 03/04).

Em Juízo, por seu turno, também confirmou sua narrativa ao prestar compromisso legal. Disse que, na data dos fatos, ele e seu colega de farda Armando dirigiram-se ao local dos fatos, que é bastante conhecido como ponto de venda de drogas; que já efetuaram diversas prisões no local em razão do crime de tráfico; que se posicionaram nas proximidades com viatura descaracterizada; que algumas imagens foram captadas de uma mulher de camiseta verde e chinelo, e de um homem de camisa estampada e bermuda, que pessoas se encontravam com eles e trocavam algo, em atitude típica de tráfico de drogas; que, em dado momento, um rapaz de camiseta vermelha, que também realizou troca semelhante às anteriores; que, ao sair do local, este foi abordado e foi localizado um pino de cocaína e ele disse que havia adquirido no local dos fatos; que, em seguida, pegaram uma viatura caracterizada, quando foi feita a abordagem dos acusados; que nada de ilícito foi encontrado com GERSON; que, após, foram encontrados 09 pinos com cocaína; que no trajeto à delegacia, ELENI entregou R\$40,00 aos policiais; que ELENI e GERSON reservaram-se ao direito ao silêncio; que GERSON era conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas; que permaneceram no local dos fatos por aproximadamente 1 hora; que GERSON e ELENI estavam próximos um do outro no dia dos fatos; que, com a testemunha Amarildo, foi encontrado um pino de cocaína; que tirou fotografias de dentro da viatura, com uso de recurso ótico de aproximação.

Por sua vez, a testemunha Amarildo Sobral Rodrigues narrou, perante a Autoridade Policial, que: "na data de hoje, policiais civis abordaram-no na Rua Claudino Novais, esquina com a Rua João Felizardo, próximo ao campo do areião, e perguntaram sobre a existência de algum objeto ilícito em sua posse, e que de pronto informou possuir uma porção de "cocaína" dentro do bolso de sua bermuda, a qual fora entregue aos policiais. Que os policiais continuaram a busca pessoal, entretanto não foram localizados quaisquer outros objetos ilícitos em sua posse. Diante dos fatos, fora conduzido até a Autoridade Policial, juntamente da substância

apreendida em sua posse, para as devidas providências legais cabíveis ao caso. Indagado pela Autoridade, respondeu que é usuário de drogas, especificamente cocaína, há aproximadamente 4 (quatro) meses e que adquiriu a porção de drogas de uma pessoa desconhecida, nas imediações do beco do banana, do qual não soube identificar características físicas, e que pagou a quantia de R\$10,00 (dez) reais pela porção da droga." (fl. 05).

Por sua vez, em seu interrogatório em Juízo, o acusado GERSON DA CRUZ LIMA negou a prática delitiva a ele imputada na exordial acusatória. Narrou que, naquele dia, foi ao local dos fatos para comprar drogas porque é usuário; que costumava usar maconha e cocaína; que costuma comprar drogas naquele local, já que mora ali perto, na cidade de Cajati; que foi abordado por três policiais no "Bar do Roberto"; que, no dia dos fatos, comprou dois pinos de cocaína por R\$20,00; que entregou o dinheiro a um rapaz, desconhecido, que usava boné, para comprar dois pinos de cocaína, mas este não regressou e, nesse intervalo, foi abordado por policiais; que, naquele dia, algumas pessoas se aproximaram de si porque acharam que estava vendendo drogas no local, mas não estava; que nunca havia visto ELENÍ antes daquele dia; que não a conhecia anteriormente.

Por fim, em seu interrogatório em Juízo, a acusada ELENÍ AGUIAR DOS REIS também negou a traficância. Disse que é usuária de drogas e faz tratamento no CAPS; que, na data dos fatos, havia abandonado o tratamento e consumido bebidas alcoólicas e 20 pinos de cocaína e estava muito agitada; que não comia, dormia ou ia para casa há três dias; que não conhecia GERSON anteriormente; que apenas se aproximou dele para perguntar se a biqueira estava aberta; que, naquele dia, havia comprado 09 pinos de cocaína e tinha R\$40,00 para comprar mais 04; que foi esse dinheiro que entregou aos policiais que a abordaram; que foi abordada no "Bar do Roberto" onde consumia bebida alcoólica; que, naquele dia, apenas conversou com Roberto e conhecidos dele.

Pois bem.

Primeiramente, há que se ressaltar, no que tange ao depoimento de policiais, civis e militares, que não há dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que, no desempenho de suas atuações, agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Nessa linha de raciocínio, já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O c. Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória apta a sustentar um decreto condenatório. Nada existe de concreto nos autos a indicar

que os agentes públicos, ouvidos em Juízo e em sede policial, estivessem tentando incriminar injustamente os Réus, atribuindo-lhes o falso cometimento de um delito.

Ademais, no caso concreto, a dinâmica narrada pelos agentes públicos foi corroborada nos autos pelo depoimento da testemunha civil, Amarildo, usuário de drogas, a qual confirmou ter adquirido um pino de cocaína de uma pessoa desconhecida na data e no local dos fatos, pouco antes da prisão em flagrante dos acusados, sendo certo que, de acordo com o depoimento das testemunhas, corroborados pelas fotografias de fls. 31/32, o pino encontrado com Amarildo era idêntico àqueles que foram apreendidos na posse de ELENÍ.

Ainda a corroborar com a robusta prova oral produzida em Juízo, tem-se as fotografias colacionadas às fls. 22/32 dos autos, efetuadas momentos antes da prisão em flagrante dos acusados, as quais registraram GERSON e ELENÍ conversando por diversas vezes na data e no local dos fatos, bem como repassando objetos um para o outro e para terceiros, que do local se aproximavam, de modo que sua versão, no sentido de que não se conheciam anteriormente, revela-se completamente inverossímil, pois dissociada dos elementos informativos e das fontes de prova reunidas ao longo das duas fases da persecução penal.

Nesse sentido, segundo se extrai do acevo probatório colacionado aos autos, restou demonstrado, além de qualquer dúvida razoável, que os acusados GERSON e ELENÍ traziam consigo, na data dos fatos, 09 (nove) eppendorff's contendo aproximadamente 13,92 gramas de cocaína, para fins de comércio ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Anote-se que, apesar de a quantidade de entorpecente apreendida não ser de expressiva monta, as circunstâncias do encontro da droga, isto é, fracionada em pequenas porções para pronta venda, bem como em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes na cidade, notadamente considerando a região e as apreensões da mesma substância comumente nela realizadas, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não (apenas) a finalidade para o uso próprio.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de que o Réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga, especialmente porque o tipo penal é misto alternativo e a prática de qualquer conduta do núcleo do tipo caracteriza o delito. Nesse sentido, conforme trecho do v. Acórdão proferido na Apelação nº 0000926-20.2016.8.26.0616, “[p]or outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda” (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

Por fim, quanto à possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no caso em apreço, conforme requerido pela Defesa Técnica, é certo que o benefício legal tem como finalidade prestigiar os chamados “pequenos traficantes”, devendo, portanto, seus requisitos legais serem interpretados de forma restritiva.

No caso concreto, notadamente após análise das certidões colacionadas às fls. 174/184, entendo que ambos os acusados devem ser beneficiados com a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Apesar de o referido dispositivo legal dispor que a reincidência, os maus

antecedentes e a dedicação a atividades criminosas são empecilhos à incidência da atenuante, entendendo ser necessário, para afastar o benefício legal, que haja sentença(s) condenatória(s) com trânsito em julgado proferida(s) em outro(s) processo(s) em desfavor do acusado, ou, ao menos, a existência de situações evidentes de dedicação a atividades criminosas, a exemplo da ocorrência de prisões em flagrante reiteradas em curto espaço de tempo.

No caso em apreço, tais circunstâncias não se revelaram da instrução processual. Quanto à acusada ELENÍ, verifica-se que, apesar de já ter sido condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, sua pena foi extinta em 2012 (fls. 180/181), revelando que há aproximadamente 10 anos não se envolveu com outras práticas criminosas, até o presente caso. Por seu turno, quanto ao acusado GERSON, verifica-se que foi condenado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, apenas em primeira instância, tendo sido beneficiado com a conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 185/186), circunstâncias que denotam, além da ausência de definitividade da condenação, a pouca gravidade do caso anterior e a baixa periculosidade do agente.

Por seu turno, conforme a Teoria da Indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao Réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, os Réus sequer alegaram a existência de causas excludentes da ilicitude. Além disso, inexistem nos autos qualquer elemento que aponte que agiram de forma justificada. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da Teoria Normativa Pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que os Réus sequer suscitaram a existência de dirimentes. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto os Réus são imputáveis e dotados de potencial consciência da ilicitude, bem como lhes era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação dos Réus GERSON DA CRUZ LIMA e ELENÍ AGUIAR DOS REIS pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CFB, art. 5º, inciso XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

II.I. Do Acusado GERSON DA CRUZ LIMA

Das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: conforme registram as certidões de fls. 182/184 e 185/186, o acusado não ostenta condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor, razão pela qual a presente circunstância não poderá ser valorada negativamente, nos termos do Enunciado de Súmula nº 444 do c. Superior Tribunal de Justiça; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu,

razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais. Dessa forma, a presente circunstância será considerada como neutra; g) Consequências do crime: são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e quantidade da droga: não há razões para serem consideradas negativas. Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena mínima cominada e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem valoradas. Por outro lado, nos termos da fundamentação, aplico a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e, ausente qualquer elemento concreto em prejuízo do Réu, a pena intermediária deve ser diminuída na fração máxima de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do Réu.

Impede salientar, por fim, que o c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei nº 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Assim, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, bem como o fato de o Réu ser tecnicamente primário, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana, feriado e dias de folga, bem como nos demais dias entre as 22h00min e às 06h00min; b) Não se ausentar da Comarca sem prévia e expressa autorização do Juízo; e c) Comparecer bimestralmente a Juízo, para informar e justificar suas atividades.

Considerando, entretanto, que o Réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal, e a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinado à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º).

Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (CP, art. 77, inciso III).

II.II. Da Acusada ELENI AGUIAR DOS REIS

Das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: conforme certidões de fls. 174/179 e 180/181, a acusada registra condenação criminal definitiva por fato anterior ao presente nos autos do Processo nº 0009721-05.2007.8.26.0495, razão pela

qual a presente circunstância será valorada negativamente (cf. STF, RE 593.818/SC); c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida da acusada em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade da Ré, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais. Dessa forma, a presente circunstância será considerada como neutra; g) Consequências do crime: são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e quantidade da droga: não há razões para serem consideradas negativas. Assim, diante da presença de 01 (um) vetor desfavorecido, elevo a pena mínima cominada e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem valoradas. Por outro lado, nos termos da fundamentação, aplico a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e, ausente qualquer elemento concreto em prejuízo da Ré, a pena intermediária deve ser diminuída na fração máxima de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira da Ré.

Impede salientar, por fim, que o c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei nº 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Assim, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, bem como o fato de a Ré não ser reincidente, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Permanecer recolhida em sua residência nos finais de semana, feriado e dias de folga, bem como nos demais dias entre as 22h00min e às 06h00min; b) Não se ausentar da Comarca sem prévia e expressa autorização do Juízo; e c) Comparecer bimestralmente a Juízo, para informar e justificar suas atividades.

Considerando, entretanto, que a Ré preenche os requisitos do art. 44, I a III, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal, e a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinado à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º).

Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (CP, art. 77, inciso III).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para:

III.I. CONDENAR o Réu GERSON DA CRUZ LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal, e a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinado à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º); e

III.II. CONDENAR a Ré ELENÍ AGUIAR DOS REIS, qualificada nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal, e a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinado à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º).

IV- DISPOSIÇÕES FINAIS

IV.I. CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Em se tratando de Ação Penal Pública, compete ao Juízo da Execução Penal a análise do estado de miresabilidade jurídica do condenado, visando à concessão do benefício de gratuidade da justiça (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

IV.II. Conforme determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva da Ré ELENÍ AGUIAR DOS REIS por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como considerando o fato de que foi condenada à pena a ser cumprida em regime inicial aberto, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos.

No mesmo sentido, REVOGO a prisão preventiva do Réu GERSON DA CRUZ LIMA por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como considerando o fato de que foi condenado à pena a ser cumprida em regime inicial aberto, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos. EXPEÇA Alvará de Soltura clausulado em favor do sentenciado. EXPEÇA-SE o mais necessário.

IV.III. Considerando a demonstração de que o numerário apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal c/c art. 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos às fls. 18/19. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE à reversão da quantia em favor do FUNAD.

IV.IV. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

IV.V. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intímem-se os Réus para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSCGJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a

movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos conclusos. para declaração da extinção da pena.

IV.VI. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (Lei nº 11.343/06, art. 72), caso a providência já não tenha sido adotada.

IV.VII. Fixo os honorários advocatícios do(s) patrono(s) de acordo com a tabela do convênio celebrado entre a OAB/DPE. Expeça(m)-se certidão(ões) a qual ficará disponível através do sistema SAJ para que o advogado, após a devida conferência, providencie sua impressão.

IV.VIII. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

IV.IX. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Jacupiranga, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA